

1500617-78.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 3ª Vara Cumulativa

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... pensão alimentícia e o ENDRIO por tráfico de entorpecente. Eu já conhecia o ENDRIO nos meios policiais. A gente passava, e tem a famosa biqueira que a gente fala, e o ENDRIO sempre estava ali realizando vendas de entorpecentes, só que nunca conseguimos pegá-lo e fomos pegá-lo dessa forma. Já sabíamos que o ENDRIO estava realizando tráfico pelo local, que é a umas duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

3ª Vara Cumulativa

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500617-78.2022.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500617-78.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ENDRIO HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de ENDRIO HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, em 01/06/2022, por volta das 16h00min, na Rua Aristides Moretti, 177, Lençóis Paulista, incumbidos de cumprir um mandado de prisão civil em desfavor de Rogério Cardoso Adão, residente no endereço acima, policiais militares adentraram na sua casa, quando, então, teriam se deparado com sacos plásticos típicos para embalagem de entorpecentes, próximos ao réu - também morador do imóvel -, tendo ele prontamente confessado aos agentes que guardava drogas, indicando-lhes o local, onde foram encontrados 19 porções de cocaína, pesando 4,04 gramas, 17 porções de crack, de 12,04 gramas, e uma porção de maconha, com peso de 32,83 gramas, além dos próprios sacos plásticos e uma balança de precisão. Aduziu o Parquet que o réu teria confessado a traficância extrajudicialmente. Requereu, assim, que o réu fosse incurso no tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com a respectiva condenação. A denúncia, de fls. 81/84, está acompanhada do auto de prisão em flagrante e documentos de fls. 01/78, de que consta que, na audiência de custódia, foi determinada a segregação cautelar do réu (fls. 58/61).

Notificado, o réu, mediante defensor nomeado, apresentou defesa preliminar às fls. 117/120, aduzindo não haver certeza de sua autoria, eis que a droga foi encontrada em uma casa onde moravam duas pessoas, sendo que no momento de sua abordagem estava dormindo e não possuía valores em espécie, de modo que não haveria mínimas evidências de que estava a traficar, requerendo, assim, a rejeição da denúncia ou a sua absolvição sumária.

As fls. 134/135, a denúncia foi recebida, sendo designada audiência de instrução para o dia 06/09/2022.

De ofício, na forma do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, em 26/08/2022 foi revisitada a necessidade da prisão preventiva, ficando mantida (fls. 172/173).

Na audiência, foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas arroladas pela Acusação e uma pela Defesa e o interrogatório do réu. Após, foi determinado o encerramento da instrução, oportunizando-se às partes a apresentação de razões finais escritas (fls. 195/198).

O Ministério Público ofereceu seus memoriais às fls. 205/215, ratificando os termos da denúncia, frisando não ter havido nulidade probatória na conduta dos policiais na colheita da prova, tendo encontrado as drogas sem qualquer desvio de finalidade, com evocação do princípio da serendipidade; e pugnando pela decretação de pena privativa de liberdade em desfavor do réu, com exasperação da pena na primeira fase da dosimetria em razão de maus antecedentes e na segunda fase pela reincidência específica, sem possibilidade do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 219/221, basicamente reiterando os termos da resposta à acusação, motivo pelo qual requereu absolvição do réu.

Após, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

É o caso de declarar a nulidade da apreensão da droga realizada, com a consequente absolvição do réu, tendo em vista a patente ilegalidade na obtenção das provas perpetrada pelos agentes policiais.

Conforme consta da inicial, policiais militares estavam munidos de um mandado de prisão civil em desfavor de ROGÉRIO CARDOSO ADÃO, tendo se dirigido até a casa dele para efetuar a segregação, oportunidade em que observaram petrechos utilizados para tráfico de drogas perto do réu, também morador do local, que, sem saída, resolveu confessar o comércio espúrio, apresentando as drogas aos agentes.

Ouvidos em juízo, os policiais civis afirmaram aproximadamente o seguinte, conforme anotações deste magistrado:

PM LUÍS CLÁUDIO ANDREOTTI JÚNIOR: Recebemos denúncia anônima via COPOM, em que um indivíduo estaria por esse local e estaria com mandado de prisão por pensão alimentícia. Fomos até o local, e o ROGÉRIO estava trabalhando em uma obra do lado da casa dele. Abordamos, perguntamos o seu nome e pesquisamos novamente para confirmar que realmente estava com mandado de prisão. Pedimos a cédula do RG, [...], e ele informou que estaria na estante da casa dele, que era do lado da obra. Pedimos autorização, e o ROGÉRIO franqueou a nossa entrada, fomos até a residência com intuito de pegar o RG do ROGÉRIO para apresentar na delegacia. Adentramos na residência, e observamos que no chão havia umas embalagens, um monte de saquinho no chão jogado, tipo sacolé, que é utilizado para embalagens de droga. Quando adentramos na sala, observamos que havia um indivíduo, que se levantou da cama. Quando viu que era a polícia militar, ele se deitou na cama e fingiu que estava dormindo, e isso chamou a nossa atenção. Entramos no quarto e falamos: "ENDRIO, pode se levantar, que a gente viu que você estava acordado e está fingindo que está dormindo. Se tiver alguma coisa de ilícito, já pode falar para gente onde está". E o ENDRIO falou o que tinha, falou o lugar, e até ajudou a gente; colaborou. O ENDRIO falou que a droga estava no tênis. Embaixo da cama havia um tênis, e a droga estava dentro desse tênis. Lá localizamos os 19 pinos de cocaína, mais 17 porções de crack e 32 gramas de maconha. O ENDRIO disse que estava realizando a venda. Diante disso, apresentamos o ENDRIO e o ROGÉRIO na delegacia, onde o primeiro por

pensão alimentícia e o ENDRIO por tráfico de entorpecente. Eu já conhecia o ENDRIO nos meios policiais. A gente passava, e tem a famosa biqueira que a gente fala, e o ENDRIO sempre estava ali realizando vendas de entorpecentes, só que nunca conseguimos pegá-lo e fomos pegá-lo dessa forma. Já sabíamos que o ENDRIO estava realizando tráfico pelo local, que é a umas duas quadras dessa residência em que o ENDRIO estava. O ENDRIO estava na mesma residência do ROGÉRIO. Segundo o ROGÉRIO, a casa é dele e ele deixou o ENDRIO morar um tempo ali, mas não sei em que situação que foi, se a família do ENDRIO colocou para fora... não lembro a circunstância, mas os dois estavam morando juntos, e fazia pouco tempo que o ENDRIO estava morando na residência do ROGÉRIO. Pressionei o ROGÉRIO a respeito dessas drogas, e ele disse que não sabia; só sabia que o ENDRIO estava lá, mas não sabia que ele estava realizando a venda de drogas, segundo o ROGÉRIO. A gente já sabe que o ENDRIO não é dependente químico, porque a gente já o viu na biqueira realizando venda; tanto é que indagamos ao ENDRIO, e ele confirmou que estava vendendo. O ENDRIO sabia que a gente já o tinha observado vendendo, só que até então nunca havíamos conseguido pegá-lo na biqueira; fomos pegar na residência com a droga. O ENDRIO não era pego quando estava realizando a venda porque, em um tráfico de entorpecentes, em todo lugar, eu já passei em vários locais. Tenho 26 anos de polícia, e é sempre a mesma forma: eles ficam com uma porção na mão e o resto fica escondido. Se não conseguirmos flagrar onde estão escondendo ou jogando, a gente não consegue pegar em flagrante, porque uma porção de droga que a gente aborda não vai dar em nada; vai cair como usuário, ele vai falar que usa... isso é o que acontece, e não vai preso. E toda vez que a gente abordava, o ENDRIO não tinha nada, porque a droga estava escondida, se livrava, jogava em outra residência. Geralmente ficam somente com uma porção. Por isso é que a gente não conseguia pegar. Sabíamos que o ENDRIO estava na prática do tráfico por informações que a gente já tinha e por ele estar em local que é ponto de venda. É difícil pegar o traficante, e tem traficante que esconde a duas quadras do local em que estão vendendo. Geralmente, no Bairro Ibaté é o ponto em que a gente pegava o ENDRIO. Os traficantes ficam de bicicleta. Fica um de bicicleta e um com a droga; e um vai e busca a droga para o outro vender. Então, eles vão duas quadras para baixo. Passa um carro, dá um toque que quer droga, e eles falam para o indivíduo que vai pegar a droga para dar uma volta no quarteirão, para depois voltar e pegar a droga. É o tempo que eles têm para ir até o local que deixam escondido, para pegar e fazer a troca. Por isso, a gente nunca pegou. E justamente nesse dia conseguimos pegar o ENDRIO, porque estava na residência. Nem imaginávamos que ele estaria lá. Quando a gente viu que era o ENDRIO, já sabíamos que estava com coisa errada e por isso falamos para entregar o que tivesse e indicar onde. Tanto é que o ENDRIO falou: "Perdi, senhor. Caí, estou vendendo, e a droga está aqui no tênis, embaixo da cama. Foi dessa forma que conseguimos pegar o ENDRIO.

PM DAVI CARLOS PEREIRA DOS SANTOS: Nessa data, a gente havia recebido um mandado de prisão de um indivíduo procurado pela Justiça, nessa Rua Aristides Moretti. A gente se deslocou para conduzir esse indivíduo [ROGÉRIO]. Em contato com o indivíduo, pedimos o documento, e ele disse que estaria na sua casa. Com receio de ele tentar fugir, pedimos autorização para acompanhá-lo até a sua residência para pegar o seu documento, e ele autorizou. A gente adentrou na casa desse indivíduo para pegar o documento, quando, então, nos deparamos com o ENDRIO deitado no quarto. Ele já é conhecido nos meios policiais. Quando nos deparamos com ele, tentou fingir que estava dormindo. Localizamos embalagens na residência e questionamos ao ENDRIO se havia mais alguma coisa de droga na residência, e ele falou que realmente tinha. Pegou debaixo da cama um par de tênis que havia uma quantidade de droga. Ele nos falou que realmente estava na prática de tráfico de drogas. Eu conhecia o ENDRIO nos meios policiais, ali mesmo no Bairro Ibaté, por abordagens policiais e nos locais de venda de droga. A casa da abordagem é do outro indivíduo que estava com o mandado de prisão. Esse indivíduo disse que cedia a residência para o ENDRIO dormir. Esse indivíduo não falou nada a respeito da droga. Em seguida, foi ouvido ROGÉRIO CARDOSO ADÃO, na condição de informante: Sou amigo do ENDRIO. Esses fatos aconteceram em casa, mas eu estava trabalhando.

Quando cheguei para pegar meu documento, e aí eu não sei o que aconteceu lá, fiquei esperando sentado, e a polícia estava revistando a casa. Eu tinha dado abrigo para o ENDRIO porque ele estava dormindo na rua. O ENDRIO falou que estava dormindo na rua, e aí eu dei abrigo de uma semana para ele, até ajeitar um lugar para ele. Os policiais vieram me buscar para conversar com o delegado a respeito da pensão alimentícia. Eu fui pegar meu documento, e os policiais entraram comigo para pegar meu documento, e ocorreu tudo isso. Eu estava sentado na sala e não vi quando acharam a droga. Eu estava sentado na sala; depois é que os policiais me levaram para o quarto para mostrar a droga. Os policiais começaram a revistar a casa, falaram que estava esquisito. Eu tinha saído cedo para trabalhar. Estava trabalhando, e os policiais me pegaram no serviço e me levaram lá em casa para pegar os documentos. O ENDRIO tinha saído de manhã também. Eu nem sabia que ele estava em casa. Quando eu cheguei, acho que o ENDRIO tinha voltado embora e estava dormindo. Quando eu saí de manhã, não havia droga dentro de casa. Eu conheci o ENDRIO lá na vila, mas há pouco tempo. Se ele usava drogas, essas coisas, não sei dizer. O ENDRIO veio morar comigo porque eu ia arrumar um serviço para ele, pois eu trabalho de pedreiro e ia arrumar um serviço para ele. Só que naquela semana, ele não tinha ido trabalhar, porque eu estava esperando pegar um trabalho maior para poder levar o ENDRIO. O lugar em que eu estava trabalhando no dia era perto da minha casa, na vizinhança mesmo. Quando os policiais foram me buscar, fui a pé mesmo até em casa para pegar os documentos. Para mim, não tinha nada de droga dentro de casa. Eu até falei com o ENDRIO, e ele falou que não estava mexendo com essas coisas nem nada. Então, não tinha nada realmente. Eu fiquei sentado na sala. Peguei meu documento que estava no armário e fiquei sentado ali, e os policiais começaram a revistar a casa. Não sei dizer se a polícia saiu com algum material na mão, porque eu fiquei sentado. Fui o último a sair, porque eu fechei a casa e tudo. Os policiais me mandaram ficar sentado no canto, e eu fiquei. Não sei dizer em que local a droga foi localizada, mas o cômodo foi o quarto. O ENDRIO estava pousando nesse quarto. Eu estava deixando que ele pousasse lá, porque meu irmão, que mora comigo, estava viajando. O ENDRIO era a única pessoa que estava dormindo no quarto nesse período. O quarto do ENDRIO não tem porta; então, fica tudo aberto. Eu saí para trabalhar eram umas 09h e pouco, mais ou menos. Não sei que horas eram quando voltei com a polícia, mas era na hora do almoço. Eu até deixei um feijão cozinhando lá. Como eu estava trabalhando do lado da casa do vizinho, era mais ou menos na hora do almoço. Não cheguei a conversar com o ENDRIO a respeito da droga.

Finalmente, o réu foi interrogado:

O ROGÉRIO é um amigo meu. Ele é pedreiro, e eu sou meia-colher. Eu estava morando na rua há um tempo, e o ROGÉRIO ofereceu para eu trabalhar com ele. Falou: "Fica uns dias ali em casa, eu vou pegar uma obra maior, e você vai trabalhar comigo. Você sabe rebocar, sabe assentar tijolo"; e eu aceitei porque eu já estava procurando emprego. [...] Eu tinha saído cedo atrás de procurar um "bico" para eu fazer ali por perto [...]. Voltei, me deitei na cama, e nisso, quando eu fui me levantar, pois estava cozinhando um feijão, eu fui olhar e estavam dois policiais adentrando na casa. Os policiais entraram na casa e me viram. Me mandaram voltar no quarto, deixaram o ROGÉRIO na sala, e me perguntaram se tinha droga na casa. Falei para eles que a única droga que tinha ali era maconha, porque a maconha era para eu fumar. Eu sou usuário de maconha, usuário crônico, fumo cedo, de manhã, e eu tinha um pouco de maconha. Quando os policiais grampearam a minha pessoa, eu mesmo pensei que eles estavam me levando por causa da maconha. Quando eu cheguei na delegacia, os policiais apresentaram outras drogas desconhecidas, que eram crack e cocaína. Eu não sabia também que tinha lá, e a balança de precisão. Os policiais falaram que tinha isso daí lá. Até o proprietário da casa, quando perguntarem para ele, vai afirmar que não tinha isso daí lá. Eu só fumo maconha, e o ROGÉRIO estava ali para me ajudar. Eu também não estou ali para prejudicar a pessoa dele. É isso daí que eu tenho para passar para o doutor. O policial, que é o DAVI, há um ano e quatro meses, tinha me prendido. Ele me injustiçou, forjando dentro da minha própria casa quando eu morava com meu padrasto, com minha mãe e com meus irmãos. Me injustiçou. Eu consegui provar isso daí, e eu ganhei em regime semiaberto. Fui para a colônia, e em dez dias eu ganhei minha liberdade. A única droga que eu assumi foi a maconha.

Não sabia que tinha outra droga, assumi a maconha, e eu falei: “A maconha é minha mesmo, e eu não estava vendendo. É para eu fumar”. Eu só falei isso daí lá na delegacia. Nós sabemos que os policiais colocam o que eles quiserem lá, porque eu mesmo não sabia que tinha nem crack nem cocaína, muito menos balança de precisão. Fui saber aqui no CDP de Bauru quando desceu a minha folha, em que estava escrito ali que eu fui preso com uma porção de maconha, que eram 32 gramas, e mais 19 pinos e as porções de crack e uma balança de precisão. Só fui ter ciência dessas drogas aqui. Essas drogas para mim são desconhecidas; eu não sei de onde vieram. Eu peguei mesmo a maconha. A maconha estava comigo. Eu mostrei para o policial a maconha. Nisso, o ROGÉRIO estava na sala, e os policiais me puxaram de canto, ficaram revirando lá, reviraram a casa inteira do ROGÉRIO. Não pegaram meus documentos. Me levaram sem documento nenhum para a delegacia. O policial, creio eu, que tem que apresentar o documento da pessoa para fazer o B.O. Eles nem apresentaram meu documento. No outro dia já me levaram preso. Eu estava morando na rua. Eu já tinha essa droga. A droga é um pedaço. São 33 gramas. Um baseado é meio grama. Quando você bola um baseado, você fuma, e eu sempre deixava um pedacinho para eu fumar no decorrer do mês. Eu estava atrás de um bico para eu fazer, porque até mesmo a obra que o Rogério iria pegar não estava certo ainda. Era uma casa que ele ia pegar. O Rogério falou para mim: “Eu estou esperando uma confirmação do moço, e eu te levo”. Daí eu tinha falado: “Eu vou atrás de um serviço cedo aí, para ver se eu consigo um biquinho ali de assentar uns tijolos por alguns dias, para eu ganhar um dinheiro. Pois bem.

Consoante se percebe dos depoimentos judiciais dos policiais militares, eles primeiramente se deslocaram até uma obra onde ROGÉRIO ADÃO estava, tomaram sua qualificação e permitiram-lhe que fosse à sua casa buscar seus depoimentos para, em seguida, ser conduzido à delegacia, onde seria efetivada sua prisão. Segundo os militares, ROGÉRIO franqueou-lhes a entrada na casa, sendo que, neste momento, os agentes constataram a presença de sacos plásticos pelo chão e o réu deitado na cama, fingindo que dormia, o que fez com que o exortassem nominalmente para que apresentasse o que quer fosse de ilícito que estaria em sua posse. Então, resignado, o réu lhes apontou um par de tênis onde estavam as drogas.

No entanto, é evidente a ilegalidade da ação dos policiais militares.

Prescreve o art. 5º, XI, da Constituição da República:

Art. 5º. Omissis.

[...]

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; [...].

O art. 244 do Código de Processo Penal reitera tal premissa.

Note-se que a inviolabilidade somente é quebrada em caso de flagrante delito, para evitar um desastre ou por determinação judicial, esta durante o dia.

De fato, não se verifica, a princípio, desvio de conduta dos militares ao adentrarem na casa de ROGÉRIO ADÃO a fim de aguardar que viesse com o documento em mãos, ainda que ele eventualmente não tenha autorizado os militares a ingressar no imóvel (até porque ele não nega isso categoricamente em juízo), porquanto, em se tratando de mandado de prisão, ainda que civil, há ordem judicial de segregação, a qual, por evidente, permite a entrada em casa alheia para tal fim. É claro que a conduta dos cumpridores da diligência deve se restringir à ordem que lhe foi passada para ser cumprida.

Entretanto, no caso dos autos, diversamente do que sustenta o Ministério Público, não se aplica aqui o princípio da serendipidade, por não ter havido aqui um mero encontro fortuito de provas, mas, sim, uma verdadeira revista na casa de ROGÉRIO ADÃO única e exclusivamente porque era o réu quem estava lá, inexistindo, a bem da verdade, qualquer situação objetiva que indicasse a presença de flagrante delito. Explica-se.

Segundo os policiais, o que os fez desconfiar de que havia um crime ocorrendo no momento do cumprimento da ordem de prisão foi a existência de sacos plásticos e a presença do réu ENDRIO, conhecido traficante nos meios policiais, que estava deitado na cama. Nada mais.

Não havia notícia-crime, ainda que anônima, de que o réu estava a traficar por ali ou que realmente utilizava da casa de ROGÉRIO como depósito ou guarda de drogas para o comércio espúrio por ele ou por terceiros. Tampouco foram observados movimentos estranhos de pessoas ou que o réu estivesse escancaradamente a fracionar drogas para quem quisesse ver.

Objetivamente, havia apenas sacos plásticos, que eventualmente podem ser utilizados para armazenar ou embalar drogas, e a presença do próprio réu na casa, deitado na cama, inexistindo situação de flagrante que realmente tornasse lícita a conduta dos policiais militares.

Aliás, chama a atenção o depoimento de ROGÉRIO ADÃO, que confirma que ficou sentado esperando os militares terminarem de revistar a casa. Isto é, não houve apenas a entrega de drogas pelo réu, mas também a ocorrência de uma devassa a fim de que mais evidências fossem encontradas que ligassem ENDRIO ao tráfico.

Nessa linha, consigna AURY LOPES JÚNIOR:

[...] é precisa a lição de MORAIS DA ROSA de que, "de fato, o art. 303 do CPP autoriza a prisão em flagrante nos crimes permanentes enquanto não cessada a permanência. Entretanto, a permanência deve ser anterior à violação de direitos. Dito diretamente: deve ser posta e não pressuposta/imaginada. Não basta, por exemplo, que o agente estatal afirme ter recebido uma ligação anônima, sem quem indique quem fez a denúncia, nem mesmo o número de telefone, dizendo que havia chegado droga, na casa "x", bem como que "acharam" que havia droga porque era um traficante conhecido, muito menos que pelo comportamento do agente "parecia" que havia droga. É preciso que o flagrante seja visualizado ex ante. Inexiste flagrante permanente imaginado. Assim é que a atuação policial será abusiva e inconstitucional, por violação do domicílio do agente, quando movida pelo imaginário, mesmo confirmado posteriormente. A materialidade estará contaminada pela árvore dos frutos envenenados". [destaque meu]

Além disso, é patente o desvio de finalidade, pois os policiais somente foram instados a prender ROGÉRIO, valendo-se de tal circunstância para, sponte sua, iniciarem uma investigação ali mesmo, apenas por terem visto sacos plásticos e a presença do réu.

E diz mais o indigitado autor:

Igualmente inadmissível é que seja determinada judicialmente a restrição de determinado direito fundamental do réu (inviolabilidade do domicílio, sigilo das comunicações telefônicas etc.) e essa prova venha a ser utilizada contra terceiros. Imaginemos que em determinado processo seja autorizada a interceptação telefônica do réu "A" e, na execução dessa medida, venha a ser obtida uma conversa que incrimine um terceiro "C" por outro delito. É válida essa prova em relação a "C"? Em situação similar, assim entendeu o STF, pois se a autorização judicial limitava o sigilo das comunicações de determinados réus, permitindo a interceptação de suas conversas telefônicas, parece-nos óbvio que o sigilo de terceiros não está abrangido por essa medida, pois a autorização judicial obviamente não os alcança. Mutatis mutandis, trazendo essa dicção ao caso concreto, a autorização de ingresso na casa de ROGÉRIO ADÃO (com a invasão de seu domicílio) não abrange igualmente o direito à inviolabilidade da casa por parte de seu companheiro de casa (no caso, o réu) nem dava direito aos policiais indagar imediatamente ao réu o que ele tinha de ilícito pelo simples fato de já ter sido condenado por tráfico e supostamente ainda o praticar hodiernamente. Entendimento contrário implicaria autorizar qualquer pessoa (já que a voz de prisão em flagrante é dada a qualquer do povo) invadir casas de pessoas que estejam supostamente ligadas ao crime, sem nenhum elemento objetivo prévio a indicar tal fato, e simplesmente vasculhar a habitação. Com efeito, a situação aqui tratada é similar àquela em que policiais invadem a casa de outrem sem ordem judicial e sem justa causa prévia, ainda que justificada posteriormente. É a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NO DOMICÍLIO DO RÉU. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA/COMUNICAÇÃO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. É pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protraí no tempo, o que, todavia, não

é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito

2. Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.

3. Não havendo, como na hipótese, outros elementos preliminares indicativos de crime que acompanhem a denúncia anônima, inexistente justa causa para autorizar o ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, o que nulifica a prova produzida.

4. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas colhidas mediante violação domiciliar. (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 512.418/RJ. Rel. Min. Nefi Cordeiro. Sexta Turma. DJe de 03/12/2019)

E mais do Tribunal do Cidadania, recentemente, em caso em que policiais militares cumpriam mandado de prisão, situação muito semelhante à presente, explicando o conceito de fishing expedition ou pescaria probatória:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DESVIO DE FINALIDADE NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO.

ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE E DA CORRÉ. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC n. 663.055/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, entendeu que "é ilícita a prova colhida em caso de desvio de finalidade após o ingresso em domicílio, seja no cumprimento de mandado de prisão ou de busca e apreensão expedido pelo Poder Judiciário, seja na hipótese de ingresso sem prévia autorização judicial, como ocorre em situação de flagrante delito". (HC 725892 / GO, RELATORA Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 08/04/2022).

2. Na esteira dos precedentes supracitados, não se pode admitir que a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão implique a concessão de um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente, em verdadeira pescaria probatória ("fishing expedition"), sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade.

3. No caso, não foi seguido o procedimento legal previsto no art. 293 do CPP. Além disso, os policiais visualizaram uma pessoa fugindo – não sabendo, com segurança, portanto, se era a terceira pessoa, foragida, que estavam procurando –, mas ainda assim adentraram na residência da corré e passaram a vasculhar seu interior, até encontrarem as drogas.

4. Mesmo admitida a possibilidade de ingresso no domicílio para captura de pessoa em cumprimento ao mandado de prisão, verifica-se que houve desvirtuamento da finalidade no cumprimento do ato, posto que, segundo a denúncia, as drogas estavam "escondidas em uma rede", de forma que se pode concluir que não houve mero encontro fortuito enquanto se procurava pelo foragido, mas sim verdadeira busca probatória dentro do lar, que é totalmente desvinculada da finalidade de apenas capturar pessoa foragida.

5. Desse modo, vislumbra-se a ilicitude da busca e apreensão domiciliar, e das provas dela decorrentes, inclusive a apreensão das drogas e a subsequente quebra de sigilo de dados do aparelho celular, nos termos do art. 157, caput, e § 1º, do CPP, impondo-se a absolvição do paciente e da corré, nos termos do art. 386, II, do CPP.

6. Ordem concedida para absolver o paciente e a corré em relação aos delitos previstos no arts. 33, caput, e 35, da Lei n. 11.343/2006, que devem ser colocados em liberdade, se por outro motivo não estiverem presos. (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 732.490/PA. Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região). Sexta Turma. DJe de 15/08/2022) [destaques meus]

Para além disso, poderiam os agentes policiais ter comunicado sua desconfiança à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público, para que instaurassem uma investigação a respeito, quando, então, inclusive, seria possível a infiltração de agentes ou de não-autuação sobre eventuais compradores usuários para ser possível a identificação do fornecedor, tudo na forma do art. 53 da Lei 11.343/2006. A propósito, o E.

Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, L. 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação do réu e do Ministério Público. Preliminarmente. Prova ilícita. Art. 157, CPP. Violação de domicílio. Busca e apreensão realizada sem mandado judicial e sem prévia justa causa. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais na casa do investigado. Delito de tráfico de drogas, ademais, que nem sempre traduz verdadeira urgência a justificar o ingresso sem autorização em domicílio alheio. Inteligência do art. 53, II, da Lei 11.343/06. Versão das testemunhas policiais frontalmente contrariada pelas demais provas (testemunhal e pericial) dispostas no processo. Alegação dos policiais de justa causa contrariada por testemunha de defesa, pela prova documental e pericial. Alegação dos policiais de que a entrada foi franqueada pelo réu contrariada pelos vídeos e perícia que mostram fortes indícios de arrombamento. Necessidade de respeito às garantias constitucionais, sob pena de esvaziamento do direito à inviolabilidade de domicílio. Ocorrência que, ademais, foi maculada por violência policial. Laudo de exame de corpo de delito que constatou ofensa à integridade corporal do réu, sendo que as lesões são compatíveis com as agressões relatadas por ele. Mérito. Reconhecida a ilicitude da prova, de rigor a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Prova testemunha colhida em juízo que é insuficiente para condenação. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso defensivo provido, prejudicado o recurso da acusação. (TJSP; Apelação Criminal 1508553-25.2021.8.26.0228; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022)

Repise-se que não houve qualquer alegação dos policiais ouvidos de terem eles próprios observado algum ato de mercancia ou visto alguma movimentação estranha naquele momento. Tudo foi embasado unicamente em sacos plásticos (servíveis a várias situações, inclusive embalar drogas) e no fato de o réu estar na casa, motivo pelo qual a prova obtida é ilícita, com fulcro no art. 5º, LVI, da Constituição e do art. 157 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser desentranhada dos autos, tornando, conseqüentemente, nulo o flagrante. Por fim, e apenas para reforço de argumentação, o réu não foi preso com nada de valor, nem mesmo dinheiro, e, pelo que se tem, estava morando de favor na casa de ROGERIO ADÃO, não se podendo descartar que sua confissão extrajudicial tenha sido apenas para não incriminar quem lhe deu abrigo por ser morador de rua. E, excluindo-se a apreensão, não há nada nos autos que incrimine o réu, sendo imperiosa sua absolvição.

Non liquet de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória entabulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para ABSOLVER o réu ENDRIO HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE do crime que lhe é imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DO RÉU.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo nomeado em favor do réu pelo Convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA